



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: נציגות הבית המשותף רחוב יבנה 44-46-48 רמת השרון
התובעת ע"י ב"כ עוה"ד אופיר מילר
מרחוב בלוח 2 תל אביב

נ ג ד

המשיבים: 1. עידן פרוביזור אחזקות בע"מ
הנתבעים ע"י ב"כ עוה"ד נתי אגמון
מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב

2. קפה 111 קדימה בע"מ
3. ליאור מעיין
ע"י ב"כ עוה"ד אילון עישר
מרחוב מנחם בגין 65 תל אביב

החלטה

בפני בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבים האוסר עליהם לעשות כל שינויים ברכוש המשותף של הבית ברחוב יבנה 44-46-48 רמת השרון הבנוי על חלקה 127 בגוש 6415 (להלן: **הבית**) ובכלל האמור להציב מתקנים, ריהוט וכל ציוד אחר ולבצע כל עבודה אחרת ברכוש המשותף.

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

לטענת המבקשת בדעת המשיבים לפתוח מסעדת בשרים בקומת הקרקע של הבית ולצורך כך הם פתחו פתח בקיר הבית המשותף, ככל הנראה, לצורך התקנת ארובה על קיר הבית, התקינו דק מעץ בחזית הבית, הציבו מחסן לפחי אשפה והניחו מיכל ניקוז שמן בחצר הבית. לטענת המבקשת המדובר בהסגת גבול לרכוש המשותף, בניגוד לתקנון המצוי ולהוראות הפסיקה. לטענת המבקשת בידה עילת תביעה טובה ומאזן הנוחות נוטה לטובתה – המדובר בשינוי של המצב הקיים שאם יתבצע תקשה מאוד הדרך להחזרתו לקדמותו.

המשיבה 1 טוענת כי השטח נשוא המחלוקת כלל אינו בגדר רכוש משותף אלא רכוש הפרטי על פי הסכמי רכישת הזכויות שלה ושל בעלי הדירות בבית. מכל מקום נטען כי המדובר בבית המורכב מאגפים – מגורים ומסחרי, ובפועל מתנהל הבית בדרך זו מאז הקמתו. הבקשה הוגשה בשיהוי רב שכן השימוש מבוצע במתכונת זהה מזה כ- 10 שנים. שימוש זה לאורך השנים גם מצדיק דחיית בקשה מחמת השתק ומגיעות. לבקשה לא צורפו צדדים רלבנטיים אשר עלולים להיפגע עקב ההחלטה במסגרתה והיא מביאה לשינוי המצב הקיים – העבודות כבר הסתיימו ברובן ומטרת הבקשה אך למנוע את פתיחת המסעדה. לטענת המשיבה 1 המדובר במחלוקת קניינית והמפקח נעדר סמכות עניינית לדון בה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המשיבים 2 ו-3 הוסיפו לתשובתה המשיבה 1 וטענו גם כי מבנה הפחים קיים כבר למעלה מ-7 שנים. עוד נטען כי לא הוצב כל מיכל שמן והעבודות ברכוש המשותף נעשו אך לצורך חיבור תשתית גז כאשר הפגיעה תוקנה באמצעות התקנת אבני שיש זהות לאלו הקיימות בכל הרחבה. גם לשני עסקים נוספים בבית ישנו דק עץ ברחבה המסחרית ומכל מקום ניתן לדק אישור מאת כל הגורמים הרלבנטיים ובמועד הגשת הבקשה התקנת הדק כמעט והושלמה. המנדף אמור להיות מותקן על גבי הגג הטכני, שהינו, ממילא, בבעלות המשיבה 1, ועל פי אישור העירייה. גם לעסקים נוספים בבית קיים מנדף על גבי הגג הטכני ללא כל תלונה במשך שנים ארוכות, כך גם שימוש של עסקים אלו ברחבה ובדק בעץ שהתקינו.

ביום 20.02.13 ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד עד לדיון בבקשה במעמד הצדדים.

ביום 27.02.13 נערך דיון בבקשה ונחקרו המצהירים. בסיום הדיון ניתנה לצדדים שהות להודיע אם עלה בידם להגיע להסכמות אשר ייתרו את הצורך בהכרעה בבקשה. ביום 04.03.13 נתקבלה הודעת המבקשת כי היא עומדת, למעשה, על מתן החלטה בבקשה. המשיבים מסרו תגובות להודעה זו.

דיון

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות")).
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שבישור.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתי ל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ד. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ פ"ד נו(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם בנבו]).

הוכח בפני כי בהליך דנן קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, מאחר והמדובר בבית שטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים נדרשת הכרעה אגבית בשאלה האם חלק הבית נושא המחלוקת הינו רכוש משותף או בבעלות המשיבה 1 כנטען. אף אם המדובר ברכוש משותף עדיין נדרשת הכרעה בשאלה האם המדובר ברכוש משותף לכלל הבית או שמה, כטענת המשיבים, מדובר בבית מורכב וברכוש משותף השייך לאגף המסחרי.

אעיר, כבר עתה, כי אינני מקבל את טענת המשיבים בדבר העדר סמכות המפקח לדון בבקשה או בתובענה בכללותה. אין מחלוקת כי על הבית חל פרק 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק"). המפקח מוסמך, ואף מחויב, לדון בסמכות שבגררא גם בסוגיות קנייניות המתעוררות במסגרת הליך המתנהל בפניו בסמכות (ר') רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487. זאת ועוד. גם בנוגע לבתים משותפים שטרם נרשמו מוסמך המפקח לדון בתובענה שעילתה הסגת גבול – על פי סעיף 77 לחוק הוחלו סעיפים 72-77 לחוק במלואם גם על בתים משותפים שאינם רשומים. לו סבר המחוקק כי בנוגע לבתים שכאלו הסמכות השיפוטית של המפקח מתמצית בניהול והחזקה של הרכוש המשותף כנטען, ברי כי היה מחריג את הוראות סעיף 72(ב) לחוק (כפי שעשה כן לגבי סעיפים אחרים, למשל, סעיף 62 לחוק). אולם, משהוחל סעיף 72 במלואו גם על בתים שאינם רשומים, הרי שבידי הסמכות לדון בתובענה. ויוזכר, בית המשפט המחוזי אומנם מוסמך לדון בטענות הקנייניות לגופם של דברים. אולם, בכל הקשור לחזקה ושימוש במקרקעין, קרי, תובענה לסילוק יד, הסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום (על פי סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984) או למפקח על רישום מקרקעין (בנסיבות בהן חל סעיף 72 לחוק).

שנית, אף אם המדובר ברכוש משותף כללי לבית, עדיין נדרשת הכרעה באם המדובר בהסגת גבול ברכוש המשותף או בפעולה הנוגדת את הוראות תקנון הבית או המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף (על פי מבחני המקום והזמן שנקבעו בפסיקה).

אעיר כי, אומנם, נציג המבקשת מאשר כי היא איננה נושאת בעלות אחזקת הרחבה המסחרית (עמוד 2 שורה 5) ויש באמור כדי לתמוך, לכאורה, בטענות המשיבים. צורפו גם חלקים מהסכמי רכישה שונים. אולם, אין בכך די כדי לשלול קיומן של ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.

דא עקא, בכל יתר התנאים הנדרשים לצורך מתן צו המניעה לא עמדה המבקשת, בפרט כאשר סיכויי התביעה אינם ברורים לאור המחלוקת היסודית בנוגע לזכויות הקנייניות ולאור השימושים המבוצעים בפועל בבית.

הוכח בפני כי אין בצו המניעה כדי להביא לשמירה על המצב הקיים.

כך, הוכח כי מחסן הפחים קיים כבר לפחות 5 שנים (עמוד 2 שורה 14).

כך, הוכח כי תוקן הליקוי ברכוש המשותף שנוצר בשל התקנת צינור הגז (עמוד 2 שורה 20 וכן נספח ב' לכתב התשובה של המשיבים 2 ו-3). בהקשר זה לא עלה בידי המבקשת להראות, אפילו לכאורה, כי המדובר בהתקנת מערכת כלשהי ברכוש המשותף (לבד מהעברת צנרת) ובודאי שלא מערכת ניקוז שמנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך, הוכח כי בעת הגשת הבקשה דק העץ היה בשלבי בניה סופיים, למעט השלמה ארעית לצורכי בטיחות (ר' עמוד 3 שורה 6, עמוד 4 שורות 13-15 וכן נספח ב' לתשובת המשיבים 2 ו-3).

אומנם, בנוגע להתקנת המנדף יש לכאורה בצו המניעה כדי לשמר את המצב הקיים. אולם, הוכח בפני כי, בניגוד לנטען בבקשה (סעיף 13) אין המדובר בהתקנת ארובה על קירות הבית, אלא במנדף אשר אמור להיות מותקן על גבי גג האגף המסחרי (עמוד 3 שורות 2-4). די בכך כדי לדחות את הבקשה כפי שהוגשה. עוד הוכח, ולכך חשיבות מהותית בבחינת הדברים בהקשר דנן, כי על גבי גג זה מותקן עוד לפחות מנדף אחד לבית עסק נוסף בבית - מסעדת סושי, עליו יודעת המבקשת (עמוד 2 שורות 11-12). המשיבים טוענים כי מנדף כאמור קיים גם לבית הקפה הפועל במקום.

מאזן הנוחות ושיקולי היושר משלימים ומשליכים האחד על השני ובנסיבות דנן אלו פועלים לטובת המשיבים, לגבי כל אחת ואחת מהפעולות שהמבקשת מעוניינת למנוע מהם לבצע על פי הבקשה.

לא הוכח כי מותקנת מערכת ניקוז שמנים על ידי המשיבים ומכל מקום, הליקוי ברחבה בנוגע להתקנת צנרת הגז תוקן כאמור.

הוכח כאמור כי מבנה הפחים קיים כבר מספר שנים.

בהקשר זה אעיר כי תמונה בעיני מדוע בחרה המבקשת להתייחס גם למבנה זה, בנסיבות כאמור, בבקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד. ראוי היה כי המבקשת תבהיר כי המדובר במבנה הקיים במשך שנים.

הוכח בפני כי, כאמור לעיל, בניגוד לנטען בבקשה, במועד הגשת הבקשה הדק היה במצב כמעט גמור. עוד הוכח כי גם לעסקים אחרים בבית קיים דק ברחבה, לכל הפחות, כבר משנת 2006 (עמוד 2 שורה 3). אף אם הוגשו הסתייגויות כלשהם לגבי אותם "דקים", הרי שאלו עדיין קיימים בפועל ולא ננקטו כל הליכים אשר הביאו להריסתם. בנסיבות אלו גם מניעת שימוש (במסגרת סעד זמני) מהמשיבים בדק המותקן כבר ברחבה, כפי שמבצעים העסקים האחרים בבית (שלא נתבעו בהליך זה, ולמעשה, לא הוכח כי נתבעו כלל) אינו מוצדק (ר' נספח 14 לתשובת המשיבה 1).

כך אמורים הדברים גם לגבי סגירות חורף (עמוד 2 שורה 4).

שקילת מאזן הנוחות בנוגע לדק האמור מוביל למסקנה כי לאור העובדה שהדק כבר בנוי ובפרט לאור השימוש שממילא נעשה על ידי אחרים ברחבה זו, במשך שנים, הנזק הצפוי למבקשת באם לא יינתן צו המניעה קטן לאין שיעור מהנזק הצפוי למשיבים באם יינתן צו המניעה כמבוקש.

מניעת השלמת העבודות (התקנת מעקה) ומניעת השימוש בדק עשויה להביא, מניה וביה, לעיכוב בפתיחת בית העסק לתקופה שעד ההכרעה בתובענה ולנזק כספי משמעותי. מאידך, אם בסופו של יום תתקבל התובענה, הרי שהמדובר בהתקנה הניתנת להסרה בקלות ובמהירות – אם לטענת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת במשך מספר ימים (מאז הגשת הבקשה ועד הדיון בה) הושלמה בנייתו של הדק, ברי כי ניתן יהיה באותה הקלות להסירו.

יש גם לזכור, כאמור, כי נעשה שימוש דומה ברחבה על ידי אחרים.

וידוגש, על מנת להסיר ספק, מאחר והוגשה בקשה לסעד זמני על ידי המבקשת, הרי שלא תוכל להישמע, למעשה, כל טענה של המשיבים ככלל, והמשיבים 2 ו-3 בפרט, כי סילוק ידם, אם תתקבל התובענה בסופו של יום, יביא לפגיעה בפרנסתם או במוניטין בית העסק. אם מכך חוששים המשיבים 2 ו-3 בידם הזכות לבחור שלא להפעיל את בית העסק עד לאחר גמר הדיון בתובענה. אם יבחרו להפעיל את בית העסק הרי שנוטלים הם על עצמם את הסיכון כי יתכן ותסולק ידם בסופו של יום, על כל העלויות והמשמעויות הכרוכות בכך.

גם בנוגע למנדף נוטה מאזן הנוחות לטובת המשיבים דווקא.

הוכח כי אין המדובר בארובה אשר אמורה להיות מותקנת על קירות הבית, בניגוד לנטען בבקשה. מדובר במנדף אשר אמור להיות מותקן על גבי גג האגף המסחרי ובכך מצומצמת הפגיעה הפוטנציאלית בבעלי הדירות ובמבקשת. לכך יש להוסיף כי גם לעסקים אחרים בבית מותקנים מנדפים על גבי אותו הגג במשך שנים וללא כל נקיטת הליכים משפטיים כנגדם על ידי בעלי הדירות.

מאידך, ללא המנדף לא יהיה בידי המשיבים לפתוח את בית העסק עד להכרעה הסופית בתובענה והמשמעות הברורה כי נזק כספי משמעותי. אומנם, נזק זה ניתן לפיצוי ובהקשר זה ניתן לחייב את המבקשת בהפקדת ערובה כספית משמעותית להבטחת נזקי המשיבים אם בסופו של יום תדחה התובענה. אולם, לאור העדר הפגיעה, למעשה, במבקשת בשלב הביניים, אינני סבור כי בנסיבות דנן חלופה זו ראויה.

וידוגש, אין עסקינן כאן בנזק מטרדי כלשהו למי מבעלי הדירות, אלא לטענה קניינית של המבקשת בנוגע לשימוש ברכוש המשותף בבית. משכך, אף אם יש במנדף כדי לגרום עוולת מטרד ספציפית למי מבעלי הדירות, אין בכך להצדיק מתן צו המניעה במסגרת ההליך דנן, בפרט כאשר מותקנים מנדפים של עסקים אחרים באותו המקום. הנזק הקנייני בשלב הביניים אינו מספיק כדי להצדיק מתן צו המניעה אשר הנזק הגלום בו למשיבים גבוה מאד.

אינני מוצא גם כי יהיה קושי כלשהו בהחזרת המצב לקדמותו אם, בסופו של יום, תתקבל התביעה. ברי כי המשיבים נוטלים על עצמם את הסיכון כי אם תתקבל התביעה והם יחויבו לסלק את הארובה, יישאו הם גם בעלויות התקנתה וגם בעלויות פירוקה וזאת בתוך תקופה קצרה יחסית של ניהול ההליכים העיקריים. כמובן שגם בהקשר זה לא תוכל להישמע טענתם בדבר פגיעה בעסק מתפקד כאמור לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 81/13
מס' בקשה: 16/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מבחינת שיקולי היושר גם קשה להתעלם בהכרעה בבקשה דגן מחוסרים משמעותיים בבקשה למתן סעד זמני ככלל ובקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד בפרט.

בהקשר זה לא ציינה המבקשת בבקשתה כי מבנה הפחים מותקן כבר שנים, כי מותקנים מנדפים של עסקים אחרים, כי מותקנים דקים מעץ של עסקים אחרים וכי נעשה גם על ידי אחרים שימוש ברחבה (לטובת בית קפה ומסעדת סושי). למעשה, גם חלק מטענותיה של המבקשת בבקשתה היו שגויות – כך הטענה כי אמורה להיות מותקנת ארובה על קירות הבית (סעיף 13 לבקשה) כך הטענה בדבר התקנת מיכל ניקוז שמן ברכוש המשותף (סעיף 17 לבקשה).

אומנם, המבקשת איננה מחויבת לצרף את כל בעלי העסקים או בעלי הנכסים האחרים בבית לתביעתה כאשר היא מבקשת סעד מהמשיבים בלבד. אולם, העדר צירופם של אלו מעורר שאלות ותמיהות מדוע דווקא המנדף והדק של עסק המשיבים הוא זה אשר אמור "להפריע" ומצדיק מתן סעד זמני כמבוקש.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני.

למען הסר ספק יובהר כי הצו הזמני שניתן ביום 20.02.13 מבוטל.

יובהר, בנוגע להתקנת המנדף, כי הבקשה נדחית בכל הקשור להתקנתו, כפי שנטען על ידי המשיבים, על גבי גג האגף המסחרי בלבד.

הוצאות בקשה זו יפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בתיק העיקרי.

הנתבעים יגישו כתב הגנה לתביעה העיקרית בתוך 30 יום.

דיון בתובענה נקבע ליום 29.04.13 בשעה 08:30.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ג אדר תשע"ג, 05 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב